

1500458-18.2021.8.26.0030

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... de que o réu não tinha envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Por fim, quanto às “circunstâncias sociais e pessoais” e à “conduta e aos antecedentes do agente”, apesar do réu ser reincidente no crime de tráfico de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para se imputar o crime de tráfico de drogas, sob pena de se desembocar em um direito penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé-SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500458-18.2021.8.26.0030 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500458-18.2021.8.26.0030

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2329908/2021 - Delegacia de Polícia de Itararé, 21764604 - Delegacia de Polícia de Itararé, 2104/21/409 - Delegacia de Polícia de Itararé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josiel de Farias Mendes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

JOSIEL DE FARIAS MENDES, qualificado às fls. 05, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. Portaria SVS/MS 344/98 e Portaria SPTC 136/2020, na forma da Lei nº 8.072/90, c.c. art. 61, I do Código Penal (reincidência específica - fls. 29/31), porque, supostamente, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta da 00:05 horas, na Rua Davina Melo Monteiro, altura do numeral 176, Vila Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Itararé, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (16) porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 3,58g (três gramas e cinquenta e oito centigramas), substância capaz de provocar dependência física e psíquica (auto de exibição, apreensão e constatação provisória fls.11 e 21, laudo pericial a fls.

86/89).

Narra a denúncia (fls. 97-100):

“Apurou-se que o denunciado Josiel é pessoa conhecida nos meios policiais pelo tráfico de drogas, inclusive já foi condenado com trânsito em julgado pela prática do crime hediondo.

Na data dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina pela Vila Novo Horizonte quando, ao adentrarem na Rua Davina Melo Monteiro, local já conhecido pelo tráfico de drogas, visualizaram o denunciado Josiel e um terceiro indivíduo não identificado.

O denunciado, ao notar a aproximação da viatura, dispensou um objeto no solo e empreendeu fuga junto com o terceiro não identificado. Após breve acompanhamento, Josiel foi abordado, mas o terceiro conseguiu fugir.

Por ocasião da abordagem, os Agentes Públicos apreenderam com Josiel a quantia de R\$380,25, em notas de pequeno valor espalhadas por suas roupas, além de um aparelho celular.

Regressando ao local em que o denunciado inicialmente estava, os Policiais encontraram o objeto por ele dispensado, tratando-se de 16 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para a comercialização, razão pela qual o prenderam em flagrante.

O laudo pericial de fls. 86/89, referente à droga apreendida, forneceu resultado positivo para cocaína.

A natureza e a quantidade da droga apreendida, a forma como estava embalada (porções individualizadas prontas para comercialização), as circunstâncias da apreensão, o local da abordagem, já conhecido pelo comércio ilícito, a fuga e o histórico criminal do denunciado, indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas, além de outros crimes, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo denunciado.”.

Preso em flagrante, o réu foi apresentado em audiência de custódia, na qual foi decretada a prisão preventiva.

O réu foi notificado e citado (fl. 173) e, apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 178-181).

A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2022.

Em audiência de instrução, ratificado o recebimento da denúncia, foram ouvidas duas testemunhas e, na sequência, foi interrogado o réu.

Após, superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia; e a Defesa postulou desclassificação do delito para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, e formulou teses subsidiárias.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas não restou plenamente demonstrada pela acusação, uma vez que não há provas contundentes de que a droga apreendida de fato se destinava ao consumo de terceiro, e não ao consumo próprio como alegou o réu em seu interrogatório.

Nesse sentido, a jurisprudência, consolidada pelo C. STJ e pelo E. STF, estabelece que compete à acusação demonstrar a traficância/comércio ilícito de entorpecentes, por se tratar de parte integrante do tipo subjetivo do tráfico de drogas:

SENTENÇA –[...] Cabe ao Ministério Público comprovar a imputação, contrariando o princípio da não culpabilidade a inversão a ponto de concluir-se pelo tráfico de entorpecentes em razão de o acusado não haver feito prova da versão segundo a qual a substância se destinava ao uso próprio e de grupo de amigos que se cotizaram para a aquisição. (HC 107448, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 03-10-2013 PUBLIC 04-10-2013) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. [...] AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL.

REGRAS PROBATORIAS DECORRENTES DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO [...] 2.

Todavia*, a moldura fática delineada na sentença e no acórdão não demonstrou o fim de mercancia, nem afastou de forma incontestada a afirmação do réu de que a droga apreendida destinava-se ao seu consumo pessoal.** 3. A Lei n. 11.343/2006 não

determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 4. Não por outro motivo, a prática tem evidenciado que a concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais. [...] 6. A conduta imputada pelo Ministério Público - dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de trazer consigo "11 (onze) pedras de crack, divididas em papelotes individuais e escondidas em suas partes íntimas". Em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros.*

Não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente localizado com o recorrente. Com efeito, não houve campanha policial para averiguação da conduta do recorrente, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude do fato de o coacusado - que conduzia a motocicleta - ter se evadido ao avistar a autoridade policial. 8. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos alegados na acusação - não comprovou a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do recorrente, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (STJ. REsp 1769822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Diante de tais julgados, verifica-se que não compete à defesa demonstrar que a droga se destina ao consumo pessoal, mas sim à acusação demonstrar a mercancia/entrega a terceiro. Ademais, remanescendo dúvida quanto à destinação da droga, deve-se desclassificar para consumo pessoal.

Dessa foram, à luz das provas produzidas pela acusação, não há elementos seguros e contundentes que droga de destinava à traficância, conforme os parâmetros do art. 28, §2º, da Lei 11.343/11: i) natureza e quantidade da substância apreendida, bem como a forma de seu acondicionamento; ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.

Nesse sentido, quanto à natureza e à quantidade de droga, o auto de exibição e apreensão descreve a apreensão de apenas 1 tipo de substância (cocaína) em pequena quantidade 3,58 gramas. De acordo com o réu, tal quantidade se destinaria a um consumo próprio e de amigos, reunidos em um bar. A quantidade de droga, por si só, não exclui tal narrativa.

Percebe-se, assim, que a natureza e a quantidade da droga não são suficientes, para demonstrar a traficância (1 tipo de droga, em pequena quantidade).

Ademais, quanto às condições em que se desenvolveu a ação, percebe-se que o réu não foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros.

Nesse sentido, ambas as testemunhas ouvidas nessa data narraram que estava em patrulhamento, quando avistaram o réu conversando com um indivíduo. O réu saiu andando de bicicleta e dispensou uma espécie de sacole. Abordado, nada de ilícito foi com ele encontrado, porém, ao retornarem ao local, foram localizados os entorpecentes descritos na denúncia.

Por fim, observo que o celular do réu foi apreendido, porém nada de comprometedor foi extraído, o que corrobora a tese de que o réu não tinha envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Por fim, quanto às "circunstâncias sociais e pessoais" e à "conduta e aos antecedentes do agente", apesar do réu ser reincidente no crime de tráfico de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para se imputar o crime de tráfico de drogas, sob pena de se desembocar em um direito penal do autor.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para desclassificar a conduta imputada ao réu JOSIEL DE FARIAS MENDES, já qualificado, para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e condená-lo a cinco meses de prestação de serviços à comunidade.

Contudo, considerando que o réu permaneceu preso preventivamente, declaro extinta sua punibilidade, por exaurimento do direito de exercício da pretensão punitiva (STJ. 6a Turma. HC 390.038-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 06/02/2018 (Info 619))

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Para garantia do cumprimento da medida imposta, no caso de recusa injustificada, deverá o réu ser submetido à admoestação verbal e, caso esta seja insuficiente, desde já, fixo multa no valor equivalente a 40 dias-multa, no valor mínimo.

Condeno-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita

*

Itararé, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA